

공짜노동이란 무엇인가?

포괄임금 '금지'와 '오남용 방지'는 어떻게 다른가?

—포괄임금 오남용 방지 지도 지침 시행에 부쳐—



오용 수

법무법인 광장 변호사

서울대 법학과를 졸업하고 제50회 사법시험에 합격했다. 2015년 법무법인 광장에 합류한 이래 인사·노무와 관련 소송, 기업자문을 담당하고 있다. 각종 수당 및 퇴직금, 통상임금, 근로자성, 해고 등 다양한 노동 사건을 맡아 승소한 이력이 있다.

고용노동부는 2026. 4. 8. ‘공짜노동 근절을 위한 포괄임금 오남용 방지 지도 지침(이하 ‘지도지침’)'을 발표했다. 지도지침은 포괄임금을 ‘실제 근무시간과 무관하게 임금을 사전에 정하고, 기본급과 제 수당 또는 제 수당 각각을 구분하지 않고 포괄해 지급하기로 하는 임금 산정 방법’이라고 정의하면서, “현장에서는 포괄임금 약정을 체결했다는 이유로 일한 시간만큼 임금을 지급하지 않는 불공정한 관행이 있어” 시급한 개선이 필요하다는 것을 배경으로 제시했다. 그러자 앞으로는 포괄임금제가 금지된다는 식으로 언론 보도가 되기도 했다.¹⁾

정부와 정치권이 포괄임금 내지 고정OT 약정을 이른바 ‘공짜노동’의 원인으로 지목하면서 ‘금지’ 내지 ‘오남용 방지’를 이야기해 온 것이 어제오늘의 일은 아니다. 문재인 정부는 과거 2017년경부터 포괄임금제 개선에 대한 본격적인 논의를 진행

하고 같은 해 10월 ‘포괄임금제 사업장 지도지침’ 초안을 마련했으나, 결국 정부의 임기가 끝날 때까지 발표하지 못했다. 윤석열 정부도 2022년 말경 포괄임금·고정OT 오남용 근절을 기치로 내걸었으나 별다른 성과를 보지 못했다.

이에 이번 정부는 ‘포괄임금제 원칙적 금지’를 국정과제(제95번)로 제시했고, 2025. 9. 24. 노사정 및 전문가 협의체인 ‘실노동시간 단축 로드맵 추진단’을 출범시켰다. 추진단은 같은 해 12. 30. 포괄임금 오남용 방지를 위한 제도 개선에 합의했고, 노동부는 그 연장선에서 이번 지도지침을 발표한 것이다.

그런데 필자는 이번 지도지침 및 포괄임금을 둘러싼 일련의 논의를 바라보면서, 포괄임금과 관련한 핵심적인 쟁점들이 아직 충분히 숙의되지 못한 채 공전(空轉)을 되풀이하고 있다는 느낌을 지우기 어렵다. 공짜노동 근절을 위해 포괄임금 오남용을 방지하겠다는 정치적 수사(修辭)를 남발하면서도, 정작 여기에서 말하는 공짜노동의 의미를 명확하게 짚고 넘어가지 않고 있기 때문이다.

¹⁾ 매일경제, “야근한 시간만큼 돈 다 쥐려”...포괄임금제 ‘통치기’ 9일부터 안 된다 (2026. 4. 8.)

2. 공짜노동이란 무엇인가?

이번 지도지침은 포괄임금 약정이 있더라도 “실제 근로한 시간에 따라 산정된 연장근로수당·야간근로수당 또는 휴일근로수당 등과 비교해 약정한 금액이 이에 미달하는 경우 사용자는 반드시 차액을 지급해야” 한다고 설명하고 있다. 또한 고정 OT 약정을 체결할 때도 “실제 근로한 시간과 비교해 ①약정한 금액이 실제 근로시간에 따른 법정수당보다 적을 때는 차액을 지급하고, ②약정한 금액이 실제 근로시간에 따른 법정수당보다 많을 때는 약정금액을 지급해야” 한다고 설명하고 있다. 즉 노동부는 매월 일정 시간분 내지 금액분의 연장·휴일·야간근로수당을 고정적으로 지급하는 약정의 사법상 효력 그 자체는 인정된다는 전제에서, 포괄임금 내지 고정OT 약정을 체결했다는 이유로 법률상 기준에 따라 산정된 초과분의 지급을 면탈하는 경우 이를 임금체불로 봐 그 차액을 지급하도록 하겠다는 것이다.

이번 지도지침이 발표되자, 포괄임금 금지를 주장하는 단체들은 크게 반발했다.²⁾ 이번 지도지침이 포괄임금의 원칙적 금지를 선언하지 않고 오남용만 방지하겠다고 함으로써 포괄임금으로 인해 발생하는 장시간 근로, 공짜노동 등 여러 문제를 사실상 방치하고 있다는 것이다.

이와 같은 주장의 실질적 함의는 무엇일까? 포괄임금 내지 고정OT 자체를 금지하지 않는 이상 사전에 약정된 시간보다 더 많은 초과근로를 시키면서도 차액분을 제대로 지급하지 않는 사례들이 비일비재하게 발생할 것이라는 의미일까? 아니다. 이것은 그저 겉으로 내세우는 명분에 불과할 뿐, 진짜로 주장하고 싶은 것은 따로 있다.

포괄임금을 공짜노동의 원흉으로 지목하는, 이른바 ‘포괄

임금 금지론자’들은 사용자가 근로자들과 기본급과 제 수당을 구분하지 않거나(정액급제), 연장근로수당·야간근로수당 또는 휴일근로수당을 구분하지 않고 제 수당을 포괄해(정액수당제) 산정·지급하기로 하는 포괄임금 약정을 일단 한 번 체결해 놓기만 하면 근로자를 무슨 무한동력 기계(機體) 돌리듯이 무제한으로 마음껏 사용할 수 있는 것처럼 호도(糊塗)하는 경향이 있다. 포괄임금 약정이 무슨 ‘합법적 노예계약’ 내지 ‘노동력 자유이용권’이라도 되는 양 과장하는 것이다.

그러나 사실 금지론자들 스스로도 잘 알고 있다. 위와 같이 극단적인 포괄임금 약정은 (세상은 넓으니 사례가 전혀 없다고는 단언할 수 없지만) 사실 거의 찾아보기 어렵고, 현장에서 활용되는 포괄임금 약정은 대부분 ‘매월 일정 시간분 내지 금액분의 연장·휴일·야간근로의 대가를 선(先)지급하고 실제 근로시간이 이를 초과하면 차액을 추가로 지급하는’ 형태라는³⁾ 것을 말이다. 그리고 특수하고 예외적인 경우를 제외하고는 포괄임금 약정을 체결한 근로자 중에서 사전에 약정된 연장·휴일·야간근로시간을 상회하는 초과근로를 하는 사례는 그리 많지 않으며, 사용자가 그 초과분을 지급하지 않는 사례는 거의 찾아보기 힘들다는 것을 말이다.

그렇다면 무엇이 문제라는 것일까? 여기에 본질이 있다. 포괄임금 금지론자들은 포괄임금이 야기하고 있다는 ‘공짜노동’의 의미를 노동부와 다르게 정의한다. 다시 한번 강조한다. 금지론자들이 주장하는 ‘공짜노동’은 이번 지도지침에 등장하는 ‘공짜노동’과 그 의미 자체가 근본적으로 다르다. 노동부는 법상 기준에 따라 산정된 연장·야간·휴일근로수당 액수가 포괄임금 약정에 따라 사전에 정액으로 지급된 고정수당보다 큰 경우 그 차액분에 상응하는 노동을 ‘공짜노동’으로 본다. 반면 포괄임금 금지론자들은 (i)포괄임금 약정은 사법상 무효이므

2) 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전국건설노동조합, ‘건설노동자들의 염원을 잇 밭은 포괄임금 오남용 방지 지도 지침! 포괄임금 오남용 방조 지침이다!’(2026. 4. 9.); 직장간질119 온라인노조, ‘무단 칼로는 포괄임금제를 끊어낼 수 없다-포괄임금제 원칙적 금지 없는 ‘포괄임금 오남용 방지 지도 지침’(2026. 4. 9.).

3) 이번 지도지침은 연장·야간·휴일근로수당을 구분하지 않고 제 수당을 포괄해 산정하는 경우를 ‘정액수당형 포괄임금제’로, 연장·야간·휴일근로수당을 항목별로 구분해 수당별 정액으로 산정하는 경우를 ‘고정OT제’로 각각 정의하면서 양자를 구분했다. 둘 사이에 실질적으로 어떠한 차이가 있다는 것인지, 이러한 기교적 구분이 근로자 보호의 관점에서 어떠한 유익이 있다는 것인지 매우 의문이다.

로 무효인 포괄임금 약정에 따라 지급된 고정수당은 기본급으로 의제(擬制)돼야 하며, (ii)이 경우 근로자는 연장·휴일·야간근로수당을 한 푼도 받지 못한 셈이 되므로, (iii)일체의 연장·야간·휴일근로를 전부 ‘공짜노동’으로 봐야 한다고 주장한다. 고정수당이 기본급으로 취급되면 소정근로의 대가로 평가될 테니 가만히 있어도 앉은 자리에서 통상임금이 올라가는 것은 덤이다. 이번 지도지침은 금지론자들의 이러한 극단적인 견해와는 다소 결이 다른 입장에 서 있는 셈인데, 그렇다 보니 이와 같은 반발이 이어지고 있는 것으로 보인다.

3. 포괄임금 ‘금지’와 포괄임금 ‘오남용 방지’의 차이

앞서 설명한 바와 같이 노동부는 지도지침 추진의 배경으로 국정과제 중 하나인 ‘포괄임금제 원칙적 금지’를 인용하면서도, 본문에서는 전반적으로 ‘오남용 방지’라는 용어를 사용하고 있다. 얼핏 보면 둘 다 포괄임금에 대해 이런저런 규제를 하고 제동을 걸겠다는 취지이므로 표현의 강약에 차이가 있을 뿐 실질에 있어 별 차이가 없는 것처럼 오해되기 십상이지만, ‘금지’와 ‘오남용 방지’는 ‘머느리’와 ‘취머느리’ 이상으로 완전히 동떨어진 개념이다. 양자는 포괄임금을 바라보는 양립 불가능한 관점에서 비롯한 근본적인 차이를 내재하고 있기 때문이다.

포괄임금 금지론자들 중에 포괄임금 내지 고정OT 약정에 따라 사전에 정액으로 지급하는 고정수당을 ‘그만 지급하면서’ 실제 근로시간에 상응하는 연장·휴일·야간근로수당을 지급하라고 주장하는 사람은 단언컨대 단 한 명도 없기 때문에 이들의 입장은 명확하다. 종전에 지급하던 고정수당을 ‘별다른 반대급부 없이 계속 지급하고’ 만일 연장·휴일·야간근로를 하게 된다면 그에 상응하는 연장·휴일·야간근로수당을 별도로 추가 지급하라는 것이다.

박해철 더불어민주당 의원이 2024. 6. 20. 대표 발의한 근로기준법 일부개정법률안(의안번호 2200760)을 보면 이러한 입장이 적나라하게 드러난다. 박해철 의원(안)은 근로기준법 제56조 제4항을 신설해 “사용자는 제1항부터 제3항까지에 따

라 지급해야 하는 임금⁴⁾을 근로계약에 미리 포함해 산정해서는 안 된다”고 규정하면서 부칙에 “사용자는 제56조 제4항의 개정규정에 따른 임금수준을 정할 경우 종전의 규정에 따른 단체협약·취업규칙 또는 근로계약에서 정한 임금보다 낮은 수준으로 할 수 없다”는 단서를 달아 놓았다. 연장·휴일·야간근로수당을 사전에 지급하기로 하는 약정을 체결해서도 안 되지만, 무효인 약정에 근거해 지급했던 고정수당의 반환을 구해서도 안 된다는 것이다. 사실상 종전에 지급하던 고정수당을 기본급으로 전환하라는 의미에 불과하다.

반면 노동부가 이번 지도지침에서 명시하고 있지는 않지만, 포괄임금 ‘금지’ 대신 ‘오남용 방지’를 정책 방향으로 설정한 것이 시사하는 바는 비교적 명확하다. 포괄임금 약정 자체는 사법상 유효하며, 사전에 약정한 금액이 실제 근로시간에 따른 법정수당에 미달함에도 불구하고 그 차액분을 지급하지 않는 경우에 한해 이를 ‘포괄임금 오남용’으로 봐 임금체불로 의율하겠다는 것이다. 이번 지도지침에 문제인 정부 때 마련됐으나 끝내 발표되지 않았던 ‘포괄임금제 사업장 지도지침’ 초안에 작성된 “(정액수당제는) 정액으로 지급된 수당이 실근로시간에 따라 산정된 법정수당 이상이어야 함. 다만 각 수당 항목이 법정수당을 지급한 것처럼 보이기 위해 단순히 수치를 맞추는 것에 불과하다면 해당 임금 총액을 소정근로시간에 대한 것으로 간주하고 실근로시간에 따른 법정수당을 지급해야 함” 등의 내용이 포함돼 있지 않은 점을 고려하면⁵⁾ 노동부는 사실상 ‘포괄임금 오남용’의 의미를 ‘포괄임금 약정 위반’과 거의 동일하게 사용하고 있다.

이번 지도지침이 아니더라도 사용자가 포괄임금 약정을 위

4) 연장·야간·휴일근로수당을 말한다.

5) 지도지침에 이런 내용이 포함된다면, 정액수당형 포괄임금 약정 내지 고정OT 약정에 따라 별도로 지급하는 고정수당도 경우에 따라 (단순히 수치만 맞춘 것으로 평가돼) 기본급으로 취급되는 상황이 발생하게 된다. 그러나 어떤 경우가 진정한 의미에서 별도로 지급한 경우이고 어떤 경우가 단순히 수치만 맞춘 경우인지를 구분하는 것은 현실적으로 불가능에 가깝기 때문에 이런 지도지침이 시행될 경우 현장은 극심한 혼란에 휩싸이게 될 가능성이 높다.

반해 임금을 과소 지급할 경우 임금체불에 해당하는 것은 너무나도 당연하며, 실제로 노동부는 그동안에도 포괄임금 약정을 위반해 임금을 과소 지급한 사용자들을 임금체불로 의율해 왔다. 또한 포괄임금 약정을 체결한 근로자들 중에서 사전에 약정된 연장·휴일·야간근로시간을 상회하는 초과근로를 하거나 사용자가 그 초과분을 지급하지 않는 사례는 많지 않다.

즉, (i)전면적이든 원칙적이든 포괄임금을 금지할 때는 그로 인해 촉발되는 고정수당의 기본급화로 인해 대부분의 기업이 사무직·연구직 등을 중심으로 연장·휴일·야간근로수당 추가 지급 및 통상임금 재산정 등의 이슈로 대규모의 소송·분쟁에 휩싸이거나 막대한 규모의 인건비를 추가로 지급해야 하는 처지에 놓일 가능성이 높지만, (ii)포괄임금의 오남용만 방지할 때는 극소수 예외 사례들을 제외하고는 (고정수당 초과분을 법적 기준에 맞게 정산·지급하는) 대부분의 기업이 별다른 타격을 입지 않을 가능성이 높다.

즉, 이번 지도지침은 제목에서부터 '공짜노동 근절'을 내걸고 있지만, 솔직히 이번 지도지침은 공짜노동 근절과 별 상관이 없다. 정확히는 포괄임금 자체가 공짜노동과 별 상관이 없으며, 포괄임금 약정에 따라 지급된 고정수당을 전부 기본급으로 받은 셈 처야 한다는 극단적인 논리를 전제로 하지 않는 이상 우리 사회에 포괄임금 약정으로 인한 공짜노동이 만연해 있다는 현상 진단 자체가 실제 현실에 부합한다고 보기 어렵다. 어쩌면 이번 지도지침의 진짜 의의는 노동부가 '포괄임금 오남용'의 의미를 '포괄임금 약정 위반'과 거의 동일하게 사용함으로써 위와 같은 현실 인식을 공유하고 있다는 점을 어느 정도 확인시켜 줬다는 데에 있는지도 모른다.

4. 마치며 : 정치적 논쟁을 넘어 합리적 제도 설계로

한편 이번 지도지침은 신고·감독사건을 처리할 때 “제 수당을 연장근로·야간근로·휴일근로수당 등으로 각각 구분하지 않는 정액수당제 형태의 약정도 실제 임금을 각각 구분하지

않고 지급하면 현행법에 반하므로, 연장·휴일·야간근로 시간수에 따른 연장근로수당 등을 항목별로 구분·산정하도록 지도”하겠다고 밝히고 있다.

포괄임금 내지 고정OT 약정을 체결하는 회사들 대부분은 “본 기본급에는 월 〇〇시간분의 연장·휴일·야간근로수당이 포함되어 있다(정액급제)” 내지 “월급은 기본급 0,000,000원과 000,000원의 고정 연장·휴일·야간근로수당으로 구분된다(정액수당제)”⁶⁾ 등으로 표현되는 약정을 체결하고 있는데, 이런 방식은 임금대장·임금명세서 등에 기본급, 각종 수당 및 연장·야간·휴일근로 시간 수를 기재하도록 하는 현행 근로기준법에 위반되므로(근로기준법 제48조; 위반 시 제116조 제2항 제2호에 따라 500만 원 이하의 과태료), 임금대장·임금명세서 등에 “기본급 0,000,000원, 고정 연장근로수당 〇〇시간분 000,000원, 고정 야간근로수당 〇〇시간분 000,000원, 고정 휴일근로수당 〇〇시간분 000,000원” 등으로 구분해서 기재하도록 지도하겠다는 것이다.

고정 연장·휴일·야간근로수당을 각각 따로따로 산정해야 적법하고 한꺼번에 산정하면 위법하다는 기교적 구분이 공짜노동과 장시간근로 방지에 무슨 기여를 한다는 것인지는 알 길이 없지만, 과태료 위험을 피해야 하는 사업주로서는 일단 시정 지시를 받게 되면 삼국지의 제갈량이라도 된 것처럼 고정OT 삼분지계(三分之計)를 발휘해야 하는 처지에 놓이게 될 것이다.

앞서 설명한 바와 같이, 이러한 문제가 발생하는 원인은 포괄임금을 둘러싼 여러 논쟁이 정치적 이해득실에 따라 포괄임금을 맹목적으로 악마화하는 등 선동적이고 자극적인 정치 아젠다로 소비되고 있기 때문이라고 생각된다. 이제부터라도 포괄임금에 대한 소모적인 정치 논쟁을 넘어 합리적인 토론과 제도 설계로 나아가는 계기가 마련되기를 희망해 본다. **노법**

⁶⁾ 조금 더 정확하게 표현할 때는 고정 연장·휴일·야간근로가 몇 시간인지를 구체적으로 특정하면서, 그에 상응하는 고정 연장·휴일·야간근로수당 액수(통상시급×150%×고정 연장·휴일·야간근로시간 수)도 구체적으로 특정하기도 한다.